

3. 当事人

原告(上诉人、被上诉人):某基金公司

被告(上诉人、被上诉人):某会计师事务所

【基本案情】

2015年,某基金公司通过二级市场买入福建某某公司公开发行的债券若干张。2019年,福建某某公司宣告破产,无法兑付债券本息。经法院破产清算,某基金公司损失超过3600万元,清偿率未超过2%。某会计师事务所系福建某某公司发行债券的审计机构,2018年,因其未向案涉银行函证福建某某公司定期存款是否被质押、用于担保或存在其他使用限制,也未在审计工作底稿中说明未函证的理由。福建证监局向该会计师事务所及相关注册会计师出具《警示函》。2020年,福建某某公司因上述债券发行和存续期间所披露的财务信息不实,受到中国证监会的行政处罚。某基金公司主张某会计师事务所实施了虚假陈述行为,对案涉债券得以发行、交易存在重大过错,足以影响某基金公司对福建某某公司偿债能力的判断,进而影响投资决策。故根据证券法第一百六十三条的规定,诉讼请求某会计师事务所就某基金公司的全部损失3600余万元承担连带赔偿责任,并按照一年期LPR的标准支付相应利息。

【案件焦点】

1. 某会计师事务所在案涉债券发行及存续期间是否实施了具有重大性的虚假陈述行为; 2. 某会计师事务所是否存在过错; 3. 上述虚假陈述行为与某基金公司的损失之间是否具有因果关系; 4. 某会计师事务所应承担何种形式责任及责任范围。

【法院裁判要旨】

北京市第二中级人民法院经审理认为: 关于案涉债券发行及存续期间所涉及的虚假陈述行为是否具有重大性问题。本案中, 依据已查明事实, 某会计师事务所接受案涉债券发行人福建某某公司的委托, 为福建某某公司出具了2012

年度、2013年度、2014年度及2015年度的审计报告，并作出了无保留意见的承诺。案涉债券的《14募集说明书》引用了经某会计师事务所审计并出具无保留意见的2012年至2014年三年审计报告，福建某某公司《2015年年度报告》引用了经某会计师事务所审计并出具的无保留意见2015年度审计报告。另查，福建证监局向某会计师事务所发出的《警示函》载明了某会计师事务所在福建某某公司2014年和2015年公司债券财务报告审计项目的执业过程中存在对于案涉若干账户未函证定期存款是否被质押、用于担保或存在其他使用限制情况，也未在审计工作底稿中说明未函证的理由的问题，依据该《警示函》可以认定某会计师事务所未函证定期存款受限事项的事实客观存在。2020年7月13日，证监会向福建某某公司发出的行政处罚决定确定福建某某公司存在的违法事实主要是该公司在《14募集说明书》《2015年年度报告》《2016年半年报告》和《2016年年度报告》中未如实披露定期存款质押情况。综合以上事实，某基金公司诉讼主张的案涉债券在发行及存续期间存在的虚假陈述行为已经证监会做出的行政处罚决定书确认，故依据证监会向福建某某公司出具的《行政处罚决定书》认定的事实及某会计师事务所未函证定期存款受限的事实，依法认定本案诉争的虚假陈述行为具备重大性的特征。

关于某会计师事务所对虚假陈述行为是否存在过错的问题。虽然某会计师事务所按照审计准则的规定向案涉多家银行发送了询证函，但询证函事项却存在差异，如在向某银行发送的询证函事项中包含核查存款是否质押一栏，其他银行则没有。可见，其对存款是否存在质押应当进行核查是明知的。因此某银行对存款是否质押一栏未予填写情况下，其应当对此异常情况保持必要的职业谨慎和基本的警觉，追加适当的审计程序，但是，某会计师事务所在收到此回复后，并未向某银行进行进一步的询证或提出疑问。此外，有关行政监管部门亦认定某会计师事务所存在未函证案涉存款是否被质押、用于担保或存在其他使用限制，也未在审计工作底稿中说明未函证的理由等违规行为。据此，法院认定某会计师事务所并未保持注册会计师应有的职业谨慎和特别关注，导致不实审计报告的出具，且客观上的审计差错金额较为巨大，违反了《中国注册

会计师事务所第1312号——函证》(以下简称《审计准则第1312号》)的相关规定,亦符合《最高人民法院关于审理涉及会计师事务所审计业务活动中民事侵权赔偿案件的若干规定》(以下简称《审计侵权规定》)第六条规定的会计师事务所存在过失的情形,故应认定某会计师事务所在对福建某某公司的审计业务活动中存在较为严重的过失。

关于某会计师事务所的过错与损害事实之间是否存在因果关系。未披露信息对于发行人的经营状况、财务状况、持续盈利能力等综合能力具有极大影响,某基金公司亦是在参考《募集说明书》中对于发行人财务状况的介绍的基础上作出购买决定,因上述文件中的数据系经某会计师事务所审计后发布,且其就上述报告引用的数据提供了无保留意见的承诺,故在认定某会计师事务所对于其在信息披露文件中关于发行人偿付能力相关内容的重大遗漏存在过错的情况下,依法认定某基金公司的投资行为与某会计师事务所的重大遗漏行为存在因果关系。另查,某基金公司购买案涉债券的时间是在虚假陈述实施日之后,且其因持续持有该证券而产生亏损,亦可认定某基金公司的投资行为及损失与某会计师事务所的重大遗漏行为之间具有因果关系。

关于某会计师事务所承担法律责任及其范围的认定。依照《中华人民共和国证券法》等法律法规规定的立法精神,在判断证券服务机构的责任范围时,应秉持责任承担与其过错程度相适应的原则。本案中,某会计师事务所的过错形态为较为严重的过失,因此应与福建某某公司承担连带赔偿责任。另,由于福建某某公司的欺诈是造成投资人损失的直接原因、主要原因,而某会计师事务所出具不实审计报告的行为只是间接原因、次要原因,其对损害结果的原因力远远不及福建某某公司欺诈行为的原因力,故承担的连带赔偿责任应与其行为原因力程度相一致。另,综合考虑债券投资自身风险、宏观经济风险、行业风险及福建某某公司实际经营状况等因素,依法酌定某会计师事务所赔偿某基金公司损失金额为100万元。北京市第二中级人民法院判决:

- 一、某会计师事务所向某基金公司赔偿100万元;
- 二、驳回某基金公司其他诉讼请求。

某会计师事务所及某基金公司均不服一审判决，提起上诉。

北京市高级人民法院：同意一审法院裁判意见，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项、第一百八十一条之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案对审计机构承担虚假陈述侵权赔偿责任的构成要件进行了分析，总结了影响赔偿范围的原则及因素，并确定了具体的赔偿比例。本案确定的裁判思路及规则均对后续类案的审理具有借鉴及参考价值。

审理此类案件，应符合审理民事侵权案件的一般思路，同时还应考虑债券行业特殊性，并结合证券服务机构所在行业的具体规范对争议焦点予以综合认定。

一、证券服务机构承担赔偿责任构成要件分析

依据证券法第一百六十三条规定可知，证券服务机构承担赔偿责任应满足四个条件：证券服务机构存在虚假陈述行为；债券投资者等利害关系人遭受损失；虚假陈述行为与遭受损失之间具有因果关系；证券服务机构主观上存在过错。

关于证券服务机构是否存在虚假陈述行为、虚假陈述行为是否因不具有重大性而应免责。《最高人民法院关于审理证券市场虚假陈述侵权民事赔偿案件的若干规定》（以下简称《虚假陈述若干规定》）第四条规定，信息披露义务人在披露的信息中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，应当认定为虚假陈述。重大遗漏，是指信息披露义务人违反关于信息披露的规定，对重大事件或者重要事项等应当披露的信息未予披露。某会计师事务所未能向银行函证福建某某公司的定期存款是否存在质押等担保情况，导致福建某某公司因在年报及募集报告中未如实披露定期存款质押情况受到证监会处罚，应认定其披露信息存在重大遗漏。关于某会计师事务所依据《虚假陈述若干规定》第十条第三款抗辩该虚假陈述行为因不具有重大性而应免责，《全国法院民商事审判工

作会议纪要》第八十五条指出：重大性是指可能对投资者进行投资决策具有重要影响的信息，虚假陈述已经被监管部门行政处罚的，应当认为是具有重大性的违法行为。如果一方抗辩不具有重大性，应通过行政复议或行政诉讼解决。本案结合证监会向福建某某公司出具的《行政处罚决定书》认定的事实及某会计师事务所未函证定期存款受限的事实，依法认定本案诉争的虚假陈述行为具备重大性特征。

关于债券投资者遭受损失，该要件需要债券投资者对其遭受损失及损失金额予以举证，法院应对投资损失的构成及计算方法进行核实，需要注意的是，扣减债券投资者在发行人破产清算程序中或通过其他方式参与分配等已经清偿的金额。

关于虚假陈述行为与债券投资者损失之间是否具有因果关系的判断。根据《虚假陈述若干规定》第十一条规定，因果关系主要表现于债券投资者的投资决定与虚假陈述行为之间，即债券投资者因信赖证券服务机构披露的信息而作出投资决定，进而发生债券交易导致后期遭受损失。因此本要件关键是要判断债券投资者是否在虚假陈述实施日之后、揭露日或更正日之前实施了相应的交易行为，即在诱多型虚假陈述中买入了相关证券，或者在诱空型虚假陈述中卖出了相关证券，举证义务在原告。若被告能够举证存在《虚假陈述若干规定》第十二条规定的五种法定情形亦可以认定不具有因果关系，本质还在于判断虚假陈述行为与投资决定之间的关联强度。另需注意，《募集说明书》《信用评级报告》等文件虽然明确提醒投资者经营活动产生的现金流量净额“存在巨大波动风险”“可能对公司信用水平产生影响”，但该提醒是对投资者证券市场风险的一般性提示，与虚假陈述行为产生的负面影响明显不同，不能据此得出债券投资人作出自甘冒险的投资决策。

关于证券服务机构主观是否存在过错的认定，《虚假陈述若干规定》第十八条规定，法院应当按照法律、行政法规、监管部门制定的规章和规范性文件，参考行业执业规范规定的工作范围和程序要求等内容，结合其核查、验证工作底稿等相关证据，认定证券服务机构实施虚假陈述行为是否存在过错。本案中

的证券服务机构系会计师事务所，故应参考《中华人民共和国注册会计师法》《审计准则第1312号》、中国注册会计师协会发布的应用指南等行业规定。根据上述相关规定可知，会计师事务所的审计行为是否符合独立审计准则是判断其有无过错的依据。银行存款是需要函证的重要信息，函证的内容一般涉及保证、抵押或质押等事项，如果存在对询证函回函的可靠性产生疑虑的因素，注册会计师应当进一步获取审计证据以消除这些疑虑。即注册会计师在执行审计中，不仅要遵守执业准则，还要保持必要的职业谨慎。本案中，某会计师事务所在向银行函证过程中未能保持必要的职业谨慎，应认定其存在过错。《虚假陈述若干规定》第十三条则规定了过错的具体情形，包括故意和严重过失。因尚无证据显示某会计师事务所故意未对存款质押情况进行函证，结合本案查明的事实，应认定其存在较为严重的过失。

综上分析，某会计师事务所应对虚假陈述行为承担侵权赔偿责任。

二、责任形式及责任范围

证券法第一百六十三条规定，存在过错的证券服务机构应与委托人就投资者的损失承担连带赔偿责任。对于连带赔偿损失的范围，实践中，在发生债券无法按时兑付情形时，发行人往往已不具有清偿能力，此时将实施虚假陈述行为且有过错的证券服务机构纳入责任主体，有利于投资人及时得到赔偿，进而弥补损失。但证券服务机构不是发行人的“替罪羊”，在认定其赔偿范围时，基于公平原则，应秉持过罚相当的民事赔偿原则，通过认定虚假陈述行为对造成债券投资者损失的原因力程度及过错程度，据此对责任范围进行酌定，方既能平衡证券服务机构与发行人的利益，又能有效督促证券服务机构谨慎执业、勤勉尽责。

原因力程度的认定则应考虑债券投资自身风险、宏观经济风险、行业风险、债券发行人公司实际经营状况。本案中，依据上述因素可以判断某会计师事务所的虚假陈述行为是造成某基金公司损失的次要原因，故酌定某会计师事务所赔偿某基金公司100万元，赔偿比例为2%—3%。

编写人：北京市第二中级人民法院 王莹莹 王朔

特殊情形下证券虚假陈述交易因果关系的认定

——甲证券股份有限公司诉乙股份有限公司等证券虚假陈述责任案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

上海市高级人民法院(2023)沪民终591号民事判决书

2. 案由：证券虚假陈述责任纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):甲证券股份有限公司(以下简称甲证券公司)

被告(被上诉人):乙股份有限公司(以下简称乙公司)、丙技术有限公司(以下简称丙公司)、丁证券股份有限公司、戊会计师事务所(特殊普通合伙)

【基本案情】

2015年4月,作为A股上市公司的乙公司成立员工持股计划,筹资5000万元;员工持股计划设立后委托甲证券公司成立集合计划进行管理,主要投资范围为购买和持有乙公司股票;员工持股计划共15人参加,均为乙公司子公司及其关联公司的高管或主要负责人,其中周某、吴某某分别系丙公司时任法定代表人和财务负责人,周某、吴某某、付某为管委会委员,代表全体持有人行使股东权利。另外,周某、吴某某还是员工持股计划的主要出资人。

2015年5月,集合计划成立。集合计划A份额:B份额:C份额的初始配比约为9:1:2。A、B份额享有固定收益,C份额即员工持股计划享有扣除A份额和B份额的本金和预期收益及管理费、托管费等费用后的全部剩余资产和收益的分配。C份额及乙公司的实际控制人深圳市某投资有限公司对A、B份

额的固定收益承担补偿责任。

集合计划成立后，甲证券公司在员工持股计划约定的时间内买入了乙公司股票。后集合计划多次出现低于预警线或止损线情况，深圳市某投资有限公司于2016年4月至2017年5月5次向集合计划补仓。

2017年5月，因集合计划再次出现低于止损线的情形，第5次补仓未全额补足，甲证券公司遂代表集合计划向差额补偿方发出违约通知书，后卖出持有的乙公司全部股票。

2017年，就该案同一集合计划，甲证券公司曾至四川省高级人民法院起诉深圳市某投资有限公司要求承担集合计划A份额、B份额的本金及预期收益的补偿责任，并获生效判决支持。

在该案审理之前，其他投资者诉乙公司等被告证券虚假陈述责任纠纷系列案件，已由生效判决作出如下认定：乙公司应承担赔偿责任。丙公司作为重大资产重组的标的公司应向投资者承担连带赔偿责任。深圳市某投资有限公司应对乙公司的证券虚假陈述民事责任承担连带赔偿责任。周某、吴某某作为丙公司时任法定代表人和财务负责人，因虚假陈述行为受到中国证券监督管理委员会行政处罚，但未被判令承担赔偿责任。

【案件焦点】

集合计划投资决定与虚假陈述行为是否存在交易因果关系。

【法院裁判要旨】

上海金融法院经审理认为，如果被告有证据证明投资者投资决定并非被诉虚假陈述行为诱导所致，应当认定交易因果关系不成立。综合被告相关证据和本案实际情形，足以证明集合计划投资决定与虚假陈述行为不存在交易因果关系。主要基于以下因素考量，一是集合计划的成立及对乙公司股票的交易系为履行员工持股计划约定；二是C份额员工持股计划持有人中的周某、吴某某两人因实施虚假陈述行为受到行政处罚，其余13人亦系实施虚假陈述行为的丙公司及关联公司高管或主要负责人，C份额持有人对虚假陈述行为应当知情；三

是A、B 份额持有人的投资行为系对C 份额持有人和深圳市某投资有限公司连带补偿责任的信赖作出。遂根据《最高人民法院关于审理证券市场虚假陈述侵权民事赔偿案件的若干规定》(以下简称《若干规定》)第十二条第五项规定 判决:

驳回原告的全部诉讼请求。

原告不服一审判决,提出上诉。上海市高级人民法院经审理认为:集合计划是为落实员工持股计划而成立;购买乙公司股票是基于员工持股计划及其后各方签订的《资管合同》的既定安排;连带补偿责任能否履行才是真正与A、B 份额持有人利益攸关,也是A、B 份额持有人关注的焦点所在。判决如下:

驳回上诉,维持原判。

【法官后语】

本案系涉资管计划嵌套员工持股计划的证券虚假陈述责任纠纷案,涉及专业机构投资者的投资决策与证券虚假陈述是否存在交易因果关系的认定问题。本案判决明确:证券虚假陈述案件中交易因果关系的认定,无论是机构投资者还是个人投资者均平等适用信赖推定原则,但该信赖推定可以抗辩。如有证据证明机构投资者的投资决策主要基于其他因素考量而非对虚假陈述的信赖,则应当认定交易因果关系不成立。

本案的原告作为机构投资者,代表集合计划提起诉讼。该集合计划系结构化金融产品,优先级A 份额、中间级B 份额享有固定收益,风险级C 份额由上市公司员工持股计划持有,享受超额收益并承担兜底责任。实践中,有差额补足约定的结构化金融产品普遍存在。本案中,员工持股计划对虚假陈述行为应当知情,而集合计划又是员工持股计划主导设立,集合计划的投资决定并非基于对上市公司信息披露的信赖作出,法院最终判决驳回集合计划的索赔请求,体现了不因违法而获益的价值导向。

一、信赖推定原则应平等适用

现行《中华人民共和国证券法》以及《若干规定》并未对原告投资者的主体身份进行区分规定,即法律和司法解释的规定平等适用于个人投资者和机构

投资者。虚假陈述司法解释并未针对机构投资者规定更高的注意义务。虚假陈述司法解释发布后，司法实践对此应有统一认识。即无论是机构投资者还是个人投资者，只要其能够提供证据证明上市公司存在虚假陈述行为、其交易区间在实施日至揭露日或更正日之间，就应推定其交易因果关系成立。要想推翻该信赖推定的，只能由被告提供充分的证据。

二、员工持股计划对虚假陈述应当知情

信赖推定是可抗辩的，知道或者应当知道虚假陈述，构成信赖推定的抗辩事由。本案集合计划中的风险级C份额持有人即员工持股计划，对虚假陈述应当知情。员工持股计划是指上市公司根据员工意愿，通过合法方式使员工获得本公司股票并长期持有，股份权益按约定分配给员工的制度安排。在认定交易因果关系时应当充分考虑员工持股计划的特殊性。员工持股计划的参加对象及其交易安排决定了其与普通二级市场股票投资者有所区别。当员工持股计划持有人均为上市公司或关联公司高级管理人员和核心员工时，员工持股计划作出投资决策时的信息来源并非如普通二级市场投资者一般依赖于上市公司的相关信息披露，不以通过公开渠道获知的有关上市公司信息为主要决策依据，不能认定上述人员决定参加员工持股计划投资于上市公司股票系受上市公司公告中相关虚假陈述的诱导，应当推定上述人员对虚假陈述行为知情。

三、集合计划的信赖推定应当推翻

前已论及，员工持股计划对虚假陈述应当知情，但不足以直接推翻整个集合计划的信赖推定，对此尚需进一步论证。集合计划由员工持股计划主导设立的情形下，若股价波动的最终风险由明知存在虚假陈述的员工持股计划持有人承担，有证据证明其他份额持有人信赖的是增信措施而非虚假陈述，则应当认定集合计划的投资决策与虚假陈述不存在交易因果关系。本案之所以推翻信赖推定是基于多重因素的综合考量。具体包括如下三点。一是集合计划成立并购买上市公司股票系为履行员工持股计划约定。二是员工持股计划持有人对虚假陈述行为应当知情。综合员工持股计划持有人的具体构成、员工持股计划管理委员会成员情况等因素，不能认定其系受上市公司公告虚假陈述的诱导。三是

集合计划A、B 份额持有人的投资行为系基于对连带补偿责任的信赖作出。A、B 份额持有人的目标是获得固定收益，其并未因虚假陈述而采取实质性的止损举措。相反，员工持股计划和上市公司实际控制人未按约按时足额履行补仓义务时，原告即迅速发出违约通知书和集合计划到期终止公告。

编写人：上海金融法院 徐玮 杨立转 石洋洋

证券虚假陈述责任纠纷中损失核定方法的选择

——顾某某等投资人诉某科技股份有限公司证券虚假陈述责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京金融法院(2021)京74民初2117号民事判决书

2. 案由：证券虚假陈述责任纠纷

3. 当事人

原告：顾某某等投资人

被告：某科技股份有限公司

【基本案情】

2017年4月至2019年3月，某科技股份有限公司先后为多家公司提供担保。2017年4月，某科技股份有限公司签署相关协议，约定其向某公司回购信托单位，并足额支付标的信托单位转让价款，该价款最高可达56700万元。某科技股份有限公司的上述行为因构成《上市公司信息披露管理办法》第二十一条第八项规定的“重大事件”，且未按规定在相对应的年报中披露，就此被中国证监会北京监管局认定违反了2005年《中华人民共和国证券法》第六十三

条、第六十五条第五项和第六十六条第六项的规定，构成2005年《中华人民共和国证券法》第一百九十三条第一款所述的违法行为，给予某科技股份有限公司警告，同时处以40万元罚款的行政处罚。

上述信息披露后，某科技股份有限公司的股份受影响产生波动。投资者就此请求法院要求某科技股份有限公司赔偿相应损失。

【案件焦点】

法院是否应当采信损失核定机构采用的“多因子迁移同步对比法”对投资人的损失进行的核算。

【法院裁判要旨】

北京金融法院经审理认为：《最高人民法院关于审理证券市场虚假陈述侵权民事赔偿案件的若干规定》第二十四条规定，发行人在证券发行市场虚假陈述，导致原告损失的，原告有权请求按照本规定第二十五条的规定赔偿损失。第二十五条规定，信息披露义务人在证券交易市场承担民事赔偿责任的范围，以原告因虚假陈述而实际发生的损失为限。本案中，北京金融法院委托损失核定机构对投资人的损失进行了核算，损失核定机构采用了其与北京大学光华管理学院共同研发的“多因子迁移同步对比法”对投资人的损失进行核算，投资人对该方法提出异议。北京金融法院认为，首先，从程序上来讲，损失核定机构在报告中列举了可能影响股价的重大事件，各原告对此提出异议，认为影响股价的重大事件举证责任在被告某科技股份有限公司。但本案损失核定机构采用的计算方法并非事件列举法，而是就本案中选择多因子迁移同步对比法进行损失核定工作的背景进行了解释。通过所列举的事件可以看到，本案中对股价产生影响的因素不仅包括证券市场的风险和虚假陈述行为，还包括某科技股份有限公司自身经营情况等风险，故而损失核算机构才采用了本案的计算方法，以更科学、更合理、更公平地计算投资人的损失。其次，对于投资人关注的虚假陈述因素赔付率的计算方法。虚假陈述因素赔付率，是衡量投资者虚假陈述行为导致的损失在其发生的全部损失中所占比例。由于影响股价的因素众多且

无法穷尽，无法直接计量虚假陈述行为在所有影响股价因素中所占的比例。因此，损失核定机构运用金融学因子定价理论，通过模拟投资者分别在存在虚假陈述行为和不存在虚假陈述行为两种情形下发生损失的比例，达到间接计算虚假陈述因素赔付率的目的。具体的计算步骤为：(1)分别模拟存在和不存在虚假陈述行为时某科技股份有限公司股价变化。(2)计算模拟损益比例、修正后模拟损益比例。(3)从计算结果可以看出，若股价在高位时买入，虚假陈述因素赔付率较低；若股价在低位时买入，虚假陈述因素赔付率相对较高。该分布也与股票市场变化的一般规律相符，股价在高位时，股价本身累积的市场风险和价格泡沫也越高，非虚假陈述因素风险所占比例较高，虚假陈述因素的影响相对较小，相应的赔付率就低；股价在低位时，非虚假陈述因素风险所占比例较低，虚假陈述因素的影响相对较大，相应的赔付率就高。因此，通常情况下，高位买入股票的投资者其投资差额损失受其他因素的影响要大于相对低位买入的投资者，其投资差额损失可获赔比例相应地也较低。

综上，本案采用多因子同步迁移对比法核算投资人的损失，具有合理性和科学性，北京金融法院予以采纳，某科技股份有限公司应当按照核算结果向投资人进行赔付，对于部分投资人超出该核算结果的损失部分，北京金融法院不予支持。

北京金融法院判决如下：

- 一、被告某科技股份有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告损失；
- 二、驳回原告的其他诉讼请求。

判决后，双方当事人均未上诉，本判决现已生效。

【法官后语】

《最高人民法院关于审理证券市场虚假陈述侵权民事赔偿案件的若干规定》中第二十四条规定，发行人在证券发行市场虚假陈述，导致原告损失的，原告有权请求按照本规定第二十五条的规定赔偿损失。第二十五条规定，信息披露

义务人在证券交易市场承担民事赔偿责任的范围，以原告因虚假陈述而实际发生的损失为限。由此可见，发行人应当在其虚假陈述行为的范围内对投资人承

担赔偿责任。然而，在证券市场中，由于市场的复杂性和各种风险因素的存在，如社会、经济变动、发行人自身经营情况等，这些因素都会对股价的波动产生影响。因此，在虚假陈述责任纠纷案件中，如何准确认定投资者的损失，一直是一个难点和重点。

在司法实践中，过去主要采用同步指数对比法和收益率曲线同步对比法来计算投资者的损失。同步指数对比法通过对比涉案证券与相关证券市场指数，扣除系统性风险和非系统性风险，以“相对比例法”计算损失。这种方法的优势在于可解释性强，当事人便于理解，且计算复杂度低，对计算资源需求小，在一定程度上能够反映系统性风险对投资者损失的影响。收益率曲线同步对比法则采用了多因子模型法，结合事件分析法，通过对比模拟损益比例和名义损益比例来确定损失。这种方法源自金融量化交易模型，在金融行业有一定的认知度；风格因子包括9个大类46个三级因子，总体考虑因素比较全面。因此其在考虑了更多影响因素的同时，也提高了计算的准确性。

相比前两种方法，本案首次采用“多因子迁移同步对比法”核算投资者损失。从方法上看，引入了虚假陈述因素赔付率的概念，通过模拟的存在虚假陈述行为时投资者的损益比例，及不存在虚假陈述行为时投资者的损益比例，并根据投资者交易记录对相应投资者的损益比例和赔付比例进行计算，从而相对准确地衡量投资者因虚假陈述行为导致的损失在其发生的全部损失中所占比例。从计算结果上看，若投资者在股价高位时买入，虚假陈述因素赔付率较低；若在股价低位时买入，虚假陈述因素赔付率相对较高。这与股票市场变化的一般规律，即股价在高位时，股价本身累积的市场风险和价格泡沫也越高，非虚假陈述因素风险所占比例较高，虚假陈述因素的影响相对较小，相应的赔付率就低；股价在低位时，非虚假陈述因素风险所占比例较低，虚假陈述因素的影响相对较大，相应的赔付率就高非常吻合。故本案所采用的“多因子同步迁移对比法”核算投资人的损失，更合理也更科学。

证券市场虚假陈述民事责任建立的初衷，就是为了保障投资者利益、预防和遏制证券市场违规违法行为的发生，让证券市场上的相关主体为自己的侵权

行为承担相应的不利后果。所以，只有在投资者因虚假陈述行为受侵害的利益获得合理赔偿的情况下，才能通过个别交易的公正性实现和维护证券市场整体交易的公正性。北京金融法院通过探索适用“多因子同步迁移对比法”，更加精准、科学地对投资损失予以认定，生动诠释了新司法解释中填补损害功能的价值取向，既使加害人的责任得到承担，又使受害人的损害得到填补，有效地实现投资者利益保护与相关市场参与主体责任负担之间均衡，进一步优化营商环境。

编写人：北京金融法院 李方 王力群

六、信托纠纷

37

“非典型主动管理型信托”中受托管理人的 义务范围及责任认定

——某农村商业银行股份有限公司诉某信托股份有限公司
营业信托案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

上海市高级人民法院(2023)沪民终523号民事判决书

2. 案由：营业信托纠纷

3. 当事人

原告(上诉人、被上诉人):某农村商业银行股份有限公司(以下简称某农商行)

被告(上诉人、被上诉人):某信托股份有限公司(以下简称某信托公司)

【基本案情】

一、案涉信托计划设立阶段

2016年11月,某信托公司出具《尽调报告》,载明,某实业公司有意融资,故某信托公司另行设计该股权收益权模式,撰写本报告供审议。项目内容

为将信托资金用于受让某实业公司下属子公司某黄金公司15%的股权收益权，信托计划到期时，某实业公司按约定价格回购股权收益权。同时通过数据分析，得出某黄金公司具备较强的偿还能力、某实业公司发生违约风险很小等结论，同时载明了本项目各类风险。为完成上述《尽调报告》，某信托公司获取了某实业公司和某黄金公司近年来的审计报告、近期自行制作的财务报表等材料。

2017年2月28日，某信托公司（受托人）与某农商行（委托人）签订《信托合同》，约定，投资运作方式为全体委托人指定受托人以自己的名义，将信托资金用于受让某实业公司持有的目标股权收益权，并由某实业公司按照约定回购目标股权收益权，受托人为此与某实业公司签署《股权收益权转让与回购合同》，约定当某实业公司违约时，受托人有权要求某实业公司提前支付全部各期回购价款，受托人行使《股权收益权转让与回购合同》项下权利时对受益人有实质影响的，应事先征询全体受益人的意见再行使合同权利。信息披露条款约定，信托计划发生（1）信托财产可能遭受重大损失；（2）某实业公司的财务状况严重恶化等情形，受托人应当在获知有关情况后三个工作日内向受益人披露并提出应对措施。信托计划风险揭示条款披露了各项风险，并载明受托人不保本保收益。委托人的权利条款约定，受托人违反信托目的处分信托财产或者因违背管理职责、处理信托事务不当致使信托财产受到损失的，委托人有权要求受托人恢复信托财产的原状或者予以赔偿。受托人的义务条款约定，为受益人的最大利益处理信托事务，恪尽职守、履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。同日，某农商行认购该信托计划。

二、案涉信托计划实施阶段

信托计划设立后至某黄金公司违约前，某信托公司向某农商行发送《季度信托事务管理报告》以及项目检查报告，均载明，本信托计划目前尚未发现涉及诉讼或者损害信托财产、受益人利益的情形，回购方按时付息。

三、案涉信托计划违约阶段

2018年5月21日，有媒体公开报道，2018年5月4日，某黄金公司参与的其他信托计划因某黄金公司违约提前到期。某信托公司向某农商行及时告知

上述情况。之后，根据某农商行的指令，2018年6月25日，某信托公司向某实业公司发送《提前回购通知函》。

2018年7月4日，某信托公司发函向某农商行征询诉讼相关事宜。某农商行同意授权某信托公司采用诉讼方式处置本项目。某信托公司遂于2018年8月1日起诉某实业公司并获胜诉，但未执行到财产。

2018年至2020年，某信托公司五次向某农商行发送《信托事务临时披露报告》，报告诉讼案件进展情况、未来工作处置重点等事项。并按季度向某农商行发送《季度信托事务管理报告》，汇报债权催收情况。某信托公司还会同各方共同商讨债务清偿事宜，但均后续无果。

2021年12月2日，某信托公司向某农商行发送《信托事务临时披露报告》，称，公司在监管部门要求的自查工作中发现，本项目属于金融同业机构提供通道服务的业务，同时参照相关政府部门的认定，应归类为事务管理类信托……某农商行表示对此不认可，认为该信托计划应归属于主动管理类信托。

四、其他查明事实

（一）某实业公司涉讼信息

2017年3月14日，某实业公司被保全约4.4亿元的财产，2017年4月6日，因某实业公司全部清偿得以解封，该两份文书公布于2017年11月。2017年9月12日，某法院判决某实业公司向案外人支付股权转让款2500万元及相应违约金，该份文书公布于2017年12月。

（二）关于某黄金公司财务数据

某黄金公司编制的2017年3月的合并资产负债表、合并利润表显示，营业收入约119亿元，营业利润约2.3亿元，净利润约1.8亿元。

北交所交易项目公布的由某黄金公司编制的2017年第一季度财务报表显示，该公司营业收入约34亿元，营业利润约-3100万元，净利润约-3100万元。

案涉违约事发后，某农商行诉至法院，称《尽调报告》有多处虚假记载，结论缺乏专业判断，信托财产运营期间受托人未尽到诚实、信用、谨慎、有效

管理的受托人义务，应当承担违约责任，据此请求判令：1. 某信托公司赔付某农商行认购资金损失2.2亿元；2. 某信托公司赔付某农商行预期收益损失14002396.72元。

【案件焦点】

1. 案涉信托类型；2. 某信托公司是否存在违约行为；3. 若存在违约行为，如何认定赔偿范围。

【法院裁判要旨】

上海金融法院经审理认为：首先，关于案涉信托的类型。一方面，案涉信托不属于典型的通道类业务，理由如下：(1) 信托计划的融资模式是由某信托公司根据某实业公司的用资需求和意向进行设计，并制作了《尽调报告》；(2) 《信托合同》条款中明确约定，受托人应为受益人的最大利益处理信托事务，应恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，以及当信托财产可能遭受重大损失或某实业公司的财务状况严重恶化时，受托人应当在三个工作日内履行披露义务等内容，上述义务设定不符合典型通道类信托业务的特征；(3) 在案涉信托运营期间，某信托公司按信托文件约定主动向某农商行发送项目检查报告以及季度报告，该些行为在性质上应属于受托人履行的主动管理义务。另一方面，案涉信托亦与典型的主动管理型信托有所区别。受托人对信托财产的裁量权与控制权受到一定限制。例如，受托人在行使《股权收益权转让与回购合同》项下的权利时，应事先征询全体受益人的意见，根据全体受益人一致意见行使权利合同。

其次，关于某信托公司在项目成立至后期风险暴露过程中是否存在违约行为。案涉信托属于非典型主动管理型信托，应按照法定化的信义义务结合信托文件的约定具体认定受托人的履职范围。虽然《信托合同》未对尽职调查作出约定，但信托机构负有法定的尽调义务，并应对《尽职报告》的内容尽职履责。本案中，案涉信托为信用融资，信托机构应以更为严格的标准对融资人的财务数据进行审查。但对于涉及某实业公司财务状况、还款能力等核心数据，

某信托公司仅根据融资人提供的审计报告以及未经审计的财务数据作出分析并得出结论，不符合相同职业或行业中一个合格的且具有普遍谨慎的从业人员在相同或相似条件下所应采取的行为标准。

最后，关于某信托公司的责任范围如何认定。首先，案涉《信托合同》已向某农商行全面披露了信托产品的交易架构以及风险。其次，某农商行作为专门金融机构和专业机构投资者，应对其中风险均属明知，且在信息获取能力、违约风险发现和防范能力等方面均与某信托公司处于相似水准，因此，某农商行在信托设立阶段亦欠缺谨慎，同样存在过失。

综上，某信托公司在尽调过程中以及信托计划管理过程中的履约瑕疵与某农商行的损失存在一定的因果关系，但所占比重较小，并非导致投资损失的主要原因，上海金融法院酌定某信托公司承担本金部分10%赔偿比例。上海金融法院判决：

一、某信托公司偿还某农商行认购资金损失22000000元；

二、驳回某农商行其余诉讼请求。

某农商行和某信托公司均不服一审判决，提起上诉。

上海市高级人民法院经审理认为：某信托公司提供的《季度信托事务管理报告》中记载“目前尚未发现涉及诉讼或者损害信托财产、受益人利益的情形”，该报告内容与某实业公司涉讼的情况明显不符，某信托公司未尽到审慎勤勉义务。如果某信托公司能及时发现并向投资人告知涉诉情况，某农商行就可能及时采取相应风险控制措施，以减少损失，故可以认定某信托公司的未尽职的行为与投资者的投资损失间具有一定的因果关系。综合考量各种因素，一审法院的酌定责任比例具有合理性。据此，上海市高级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，作出如下判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

对于非典型主动管理型信托，应以委托人和受托人约定的信托文件为依据，遵循信托法的精神，在个案中具体裁量受托人是否尽到了信义义务。对于受托

人违反信义义务的，应审查受托人的过错行为与委托人损失之间的因果关系，并根据作用力大小判定受托人的责任比例。

一、信托机构信义义务的边界

信义义务的核心内容通常包括忠实义务和注意义务(亦称谨慎勤勉义务)。为此，我国信托法第二十五条规定：“受托人应当遵守信托文件的规定，为受益人的最大利益处理信托事务。受托人管理信托财产，必须恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。”该条对受托人的义务和权限作出了原则性的规定，将信托法上以忠实和注意义务为核心的信义义务法定化。

通常我们将信托业务分为主动管理型信托和被动(事务)管理型信托(亦称通道业务)。主动管理型信托中，信托公司可能承担产品设计、项目筛选、尽职调查、投资决策、实施和后续管理等主动管理责任。如果当事人在信托文件中约定，由委托人自主决定信托设立、信托财产运用对象、信托财产管理运用处分方式等事宜，并自行承担信托资产的风险管理责任和相应风险损失，受托人仅提供必要的事务协助或者服务，应当认定为通道业务。通道业务因不具备信托制度的价值，现已明令禁止，但对于过渡期内旧存的通道业务，除非有其他无效事由，否则司法并不否定信托业务的效力。

本案中，对照前述典型的通道类信托、主动管理型信托的核心特征，案涉信托均存在比较明显的区别，故案涉信托在性质上应当归属于非典型的主动管理型信托。

二、非典型主动管理型信托中各阶段的信义义务

信托管理中，受托人需履行尽职调查阶段、管理阶段、清算阶段的信义义务。

(一)尽职调查阶段

对于委托人针对信托项目设立提出的质疑，受托人往往会提出，信托文件未约定受托人负有尽调义务，在信托计划成立之前受托人尚不负有信托法上的信义义务，仅负有基于民法诚实信用原则的先合同义务，若受托人不存在缔约过失行为，不应承担相应的责任。

对此,如前所述,受托人的信义义务为法定义务,当事人的约定只能把受托人的行为义务具体化,但并不意味着受托人只承担约定的责任。《信托公司受托责任尽职指引》等相关文件均要求信托机构履行尽职调查义务。据此,对于非通道业务而言,信托公司在信托计划成立之前就已经负有信义义务。对于如何认定信托公司尽调是否尽职,应当以其他同行业专业金融机构的普遍实践和判断为参照和判断标准,而不应苛求其超越行业认识程度的尽善尽美。但应当注意的是,此种参照仍然是以“合格”和“普通谨慎”为前提。如果全行业均在合格的标准线下,也不能认定受托人已经尽责。

本案中,信托计划属于信用融资,然信托公司既未委托第三方专业机构出具复核的意见,亦未自行对审计报告或财务报表中记载的重要项目和数据进行再查证,不能认为是“合格”的履职行为,信托公司对此负有过错。

(二) 管理阶段的信义义务

委托人和受托人通常在信托文件中对受托人在信托项目运营管理过程中的责任和义务进行详细约定。对于非典型主动管理型信托而言,其不享有主动管理型信托中受托人可基于受益人利益最大化角度全权处理信托财产以及制定投资决策的权利,而相较于被动(事务)管理型信托,其又不仅是完全被动听从委托人指令行事。因此在认定受托人的履行标准时,需在结合信托法定化义务的前提下严格审查信托文件的约定。

本案中,信托文件已详细约定了受托人的披露义务,在涉讼信息均能通过开源信息查询的情况下,信托公司未能及时发现交易对手的涉讼情况,向受益人作了虚假报告,违背了信托文件约定的注意义务。

(三). 清算阶段的信义义务

清算阶段审查的重点应落在信托机构是否按照信托合同约定的时间、程序、方式进行清算和分配,是否存在不当侵占、挪用信托财产等情形。

三、非典型主动管理型信托中对受托人违反信义义务的责任认定

在确定责任承担的过程中,必须要考量受托人过错与投资人损失之间是否具有原因力,也即,应当反向考察受托人如果尽到了审慎勤勉义务,委托人的

损失是否可以避免或者减少。在确定受托人的失职行为与投资人损失之间具有因果关系后，还要考量受托人过错与投资人损失之间原因力的大小。据此，即便本案中受托人有履约瑕疵且与投资损失有一定的因果关系，但考虑到委托人本身身为专业投资者具有过失，最终认定某信托公司承担投资本金10%的次要责任。

编写人：上海市高级人民法院 张文婷

上海金融法院 周楠

“事务管理类信托”中受托人的义务范围及责任认定

—— 某科技公司诉某信托公司营业信托案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

广东省广州市中级人民法院(2023)粤01民终5278号民事判决书

2. 案由：营业信托纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 某科技公司

被告(被上诉人): 某信托公司

第三人：刘某

【基本案情】

2017年12月，某科技公司、刘某分别与某信托公司签订《信托合同》，约定：信托资金1.1亿元用于购买某上市公司2017年非公开发行可交换公司债券，该债券行权后转为持有某公司流通股权。行权后可依委托人指令于二级市场

场减持退出；信托的设立、信托财产的运用对象、管理、运用和处分方式等事项，均由委托人自主决定。之后，某信托公司按某科技公司、刘某指令开设证券账户，并将某科技公司、刘某投资的1.1亿元买入案涉股票。

2018年3月16日、19日，某科技公司、刘某分别向某信托公司发出《投资指令书》，要求某信托公司于2018年3月19日至21日在二级市场以不低于10.5元/股的价格出售信托持有的案涉股票750万股。某信托公司称因案涉证券账户未开通网上交易功能，故无法执行上述交易指令。

2018年3月21日，某科技公司、刘某分别向某信托公司发出《投资指令书》，要求某信托公司于2018年3月22日至26日在二级市场以不低于10.5元/股的价格出售信托持有的案涉股票750万股，并开通案涉证券账户的网上交易功能。因市场价格不符合指令交易条件，故某信托公司未执行上述交易指令。

2018年3月23日，案涉证券账户开通网上交易功能。

2018年4月2日，某科技公司与刘某分别向某信托公司发出《投资指令书》，要求某信托公司于2018年4月2日至4日在二级市场以不低于10.59元/股的价格出售信托持有的案涉股票750万股。因市场价格不符合指令交易条件，故某信托公司未执行上述交易指令。

2018年5月21日，某科技公司与刘某分别向某信托公司发出《投资指令书》，要求某信托公司于2018年5月22日通过大宗交易卖出案涉股票750万股，交易价格为每股8.66元。某信托公司最终执行该交易指令。

案涉股票在《信托合同》约定的24个月信托期限内，市场成交最高价为13.63元。

经法院向证券公司调查，证券公司称某信托公司开户时选择不开通网上委托交易权限，只保留柜台委托，某信托公司可通过柜台委托进行二级市场交易。

【案件焦点】

1.某信托公司在案涉事务管理类信托中是否违反信托义务；2.某信托公司应予赔偿的损失金额如何认定。

【法院裁判要旨】

广东省广州市天河区人民法院经审理认为：首先，案涉信托合同为集合事务管理类信托，信托财产的管理、运用及处分均由某科技公司及刘某全权决定，某信托公司是被动执行某科技公司的指令。本案中，是否开通案涉标的账户网上交易功能，属于某科技公司及刘某自主决定的对信托财产管理、运用及处分事宜。某科技公司以某信托公司未主动提示及告知开通案涉账户的网上交易功能为由，导致其错失交易时机造成损失并诉请某信托公司赔偿损失，没有合同依据。其次，某信托公司在2018年3月19日收到某科技公司及刘某达成一致的指令后，已即时按交易指令执行。从某信托公司对于交易指令的执行及按某科技公司的交易指令要求开通案涉账户网上交易功能的时间节点来看，某信托公司并不存在拖延执行某科技公司及刘某下达的指令的情形。最后，某科技公司及刘某作为合格的投资者，在案涉信托合同中选择对信托财产采取集合事务管理的自主管理信托类型，其理应对案涉信托财产交易市场的各项交易规则及相应规定有熟悉、深入的了解，并能够识别、判断及承担信托计划的相应风险。综上，一审法院驳回某科技公司的诉讼请求。

某科技公司不服一审判决，提起上诉。

广东省广州市中级人民法院经审理认为：第一，关于某信托公司是否违反信托义务。首先，案涉信托为事务管理类信托，但某信托公司只是不承担积极主动管理职责，而仍须承担账户管理以及配合委托人管理信托财产等职责。其次，某科技公司、刘某2018年3月16日、19日先后发出的两份投资指令书不存在本质差异。某信托公司不应消极地不予执行交易指令。最后，即便案涉证券账户没有开通网上交易功能，某信托公司也可通过柜台委托进行二级市场转让交易，因此某信托公司关于账户未开通网上交易功能导致其无法执行投资指令的抗辩不能成立。综上分析，某信托公司违反了信托义务。

第二，某信托公司应予赔偿的损失金额。因某信托公司未执行2018年3月19日关于以不低于10.5元/股价格出售案涉股票的交易指令，案涉股票最终按委托人指令以8.66元/股的价格成交，委托人的实际损失为1380万元。关于某

信托公司应予赔偿的损失金额，分析如下：首先，《信托合同》约定，违约方应赔偿因其违约而给守约方造成的全部损失，包括合同履行后可以获得的利益。某科技公司诉请某信托公司予以赔偿具有合同依据。其次，根据事务管理类信托的特点，对投资损失的责任比例分析如下：一方面，因某信托公司违反信托义务，未执行某科技公司、刘某于2018年3月19日发出的交易指令，导致某科技公司、刘某无法获得以10.5元/股的价格出售案涉股票的预期收益，二者之间存在一定的因果关系。另一方面，某信托公司被动执行某科技公司、刘某以8.66元/股的价格出售案涉股票的投资指令，因此造成的投资差价损失不能归责于某信托公司一方。结合案涉股票在信托期限内市场成交价，某科技公司、刘某具备减少甚至避免投资损失的可能性。因此，本案的投资损失金额是某科技公司、刘某自主指令以8.66元/股卖出案涉股票所最终确定的。综上，某信托公司违反信托义务及《信托合同》约定，系导致投资损失的诱发原因及次要原因；某科技公司、刘某自主决定以较低的卖出价格成交案涉股票，系决定原因及主要原因，故酌情认定某信托公司应对某科技公司、刘某的实际损失1380万元承担10%的赔偿责任。

广东省广州市中级人民法院判决如下：

- 一、撤销一审判决；
- 二、某信托公司向某科技公司赔偿1380000元；
- 三、驳回上诉人某科技公司的其他诉讼请求。

【法官后语】

事务管理类信托与主动管理类信托相对应，指受托人仅作为信托财产的名义所有人，对于信托财产的处分、管理不承担主动、积极的决策和执行职能，而是听从委托人或受益人的指示进行管理行为。^①对于事务管理类信托，法院应以信托合同为依据，同时根据信托法关于信义义务的规定，具体裁量受托人

^①最高人民法院民二庭编著：《〈全国法院民商事审判工作会议纪要〉理解与适用》，人民法院出版社2019年版，第462页。

是否尽到了信义义务。对于受托人违反信义义务的，应确定受托人的过错行为给委托人造成的损失大小，审查受托人的过错行为与委托人损失之间的因果关系，并根据过错及原因力大小判定受托人承担的责任比例。信义义务包括忠实义务与注意义务，本案的焦点在于受托人是否违反注意义务。

一、受托人在事务管理类信托中应承担法定及约定注意义务

在认定事务管理类信托中受托人是否违反注意义务时，应结合主客观标准进行考量。一方面，受托人的注意义务标准是客观标准，法院要根据受托人所属的社会、经济地位以及专业技能等因素认定其注意义务。^①另一方面，信托法关于注意义务的规定具有任意性规定属性，当事人可以根据信托合同的约定，加重或者减轻注意义务的标准，这使得注意义务兼有法律规定和合同约定的属性。本案中，《信托合同》约定：“受托人仅负责账户管理、清算分配及提供或出具必要文件以配合委托人管理信托财产等事务，不承担积极主动管理职责的信托业务。”根据上述合同约定，虽然案涉信托为事务管理类信托，但某信托公司只是不承担积极主动管理职责，而仍须承担账户管理以及配合委托人管理信托财产等职责。另外，信托法第二十五条规定：“受托人应当遵守信托文件的规定，为受益人的最大利益处理信托事务。受托人管理信托财产，必须恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。”根据上述规定，信托法并未免除受托人在事务管理类信托中的法定义务，某信托公司仍须承担与案涉信托类型相匹配的谨慎有效管理义务。因此无论是根据《信托合同》约定，还是根据信托法规定，均不能免除某信托公司在事务管理类信托中的注意义务。

二、受托人在关键管理环节中应承担特别注意义务

受托人在事务管理类信托中虽然没有主动管理的职责，但在账户管理以及执行指令等关键环节应当承担特别注意义务，否则将影响信托设立目的的有效实现。本案中，《信托合同》明确约定案涉股票“依委托人指令于二级市场减持退出”。某信托公司作为具有专业知识的金融机构，应当清楚案涉证券账户须具备全面便捷的交易功能。因此，信托公司在开通证券账户时应当一并开通

^①赵廉慧：《信托法解释论》，中国法制出版社2015年版，第332页。

网上交易功能，即便未开通网上交易功能，其也应通过柜台委托及时进行二级市场转让交易。但是，某信托公司在开户和交易两个环节，均未能履行谨慎、有效管理的义务，不仅在开户时选择不开通网上交易功能，而且在收到委托人指令时亦未通过柜台委托执行指令，导致最初的交易指令无法有效执行，违反了受托人应尽的注意义务。

三、委托人的实际损失可包括可得利益损失

根据信托法第二十二条规定，受托人所应承担的赔偿责任通常以信托财产实际损失为限，本质上属于一种填补性赔偿责任。但信托法并未规定损失的具体计算方式，如信托合同对于受托人的赔偿责任有相关约定的，应当遵循当事人的意思自治确定责任范围。《信托合同》约定：“违约方应赔偿因其违约而给守约方造成的全部损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时可以预见或应当预见的因违反合同可能造成的损失。”结合案涉《信托合同》的约定及民法典关于可得利益损失的相关规定，本案中可适用可得利益损失规则计算受托人遭受的损失。^①具体到本案，某科技公司的实际损失=(首次可执行交易单价-最终交易单价)×持股数量。

四、受托人的承责范围应根据其过错程度及原因力大小作出认定

事务管理类信托中，由于受托人对信托财产的处理和运用并不享有最终裁量权，受托人所需尽到的注意义务也通过信托合同的约定予以相应弱化，其违反注意义务的行为是否一定会导致信托财产遭受损失，需要根据个案进行分析。在司法审判中，法院应综合考量受托人与委托人的过错程度及造成损失发生的原因力大小，系统性评价受托人行为对损失发生所起的作用，以确定受托人的责任范围。

具体到本案，一方面，若某信托公司成功执行某科技公司的首次指令，将案涉股票以10.5元/股的价格卖出，某信托公司最终可获得的收益将处于确定状态，后续以8.66元/股的价格卖出股票的事实也就不会发生，符合主流的

^①钟瑞庆：《“违约所造成的损失”界定：理论与实证研究》，载《法学家》2022年第3期。

“若不存在某种行为，损害就不会发生”的相当因果关系推论。^①另一方面，某信托公司是按某科技公司、刘某的指令最终以8.66元/股的价格出售案涉股票，8.66元/股是某科技公司、刘某认可的交易价格，某信托公司只是被动执行该投资指令，因此造成的投资差价损失不能归责于某信托公司一方。进一步说，在案涉证券账户开通网上交易功能后，某信托公司无法执行投资指令与市场交易价未达到某科技公司、刘某指令的交易价格有关。而且，案涉股票在《信托合同》约定的信托期限内最高市场成交价为13.63元，某科技公司、刘某具备在信托期限内通过自主指定合理交易价格减少甚至避免投资损失的可能性。因此，本案的投资损失金额是某科技公司、刘某自主指令以8.66元/股卖出案涉股票所最终确定的。结合本案双方对案涉信托发生投资损失的过错程度及原因力大小，本案酌情认定某信托公司应对某科技公司、刘某的实际损失承担10%的赔偿责任。

编写人：广东省广州市中级人民法院 叶汉杰 陈然

信托财产现状分配的约定 不构成对分配债权声明数额真实性的免责

——程某某诉某某信托公司营业信托案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京金融法院(2022)京74民终214号民事判决书

^①杨立新、梁清：《原因力的因果关系理论基础及其具体应用》，载《法学家》2006年第6期。

2.案由：营业信托纠纷

3.当事人

原告(上诉人):程某某

被告(被上诉人):某某信托公司

【基本案情】

程某某于2018年1月19日与某某信托公司签订《信托合同》，于2020年5月27日签订《信托合同补充协议二》约定信托的终止日变更为2020年6月12日，并约定了信托利益的清算和分配事项，信托公司于2020年6月12日向程某某出具的《信托利益分配通知书》，载明信托公司将《信托贷款合同》项下对卜某某享有的全部债权转让给程某某，通知书附件一《贷款发放明细表》显示卜某某贷款本金金额89936.19元，剩余本金金额25114.55元。附件二《剩余债权预期还款明细表》显示卜某某预期还款合计26193.96元。程某某受让信托公司向其转让的对卜某某25114.55元的借款本金及相应利息的债权后，另案起诉卜某某还款，生效判决认定信托公司仅对卜某某享有27.53元及相应利息的债权，其他部分信托公司声明转让的债权并不真实，故起诉要求信托公司赔偿其本金及利息损失差额26166.43元。一审法院判决驳回程某某的全部诉讼请求。程某某不服一审判决上诉。

【案件焦点】

信托财产现状分配的约定是否构成对分配债权声明数额真实性的免责。

【法院裁判要旨】

北京市东城区人民法院经审理认为：原、被告签订的《信托合同》《信托合同补充协议二》系各方当事人的真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，应属合法、有效。依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。北京市东城区人民法院依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第

一条之规定，判决如下：

驳回原告的全部诉讼请求。

程某某不服一审判决，提出上诉。

北京金融法院经审理认为：根据双方之间《信托协议》《信托合同补充协议二》《信托利益分配通知书》的约定，该债权系信托公司基于信托收益分配 向程某某进行的转让，该转让为双方之间真实意思表示，合法有效，依法应当 受到保护。信托公司作为出让入及信托受托人，应当对其基于信托财产分配出 具的《信托利益分配通知书》转让债权声明数额的真实性负责；《信托协议》 约定的原状分配及诉讼风险自担的约定，并非声明数额真实性的免责，而是基 于对债务人实际履行能力的免责；某某信托公司应当对信托清算和收益分配时 转让给程某某债权的差额及利息损失承担赔偿责任。该债权转让系基于信托收 益分配，并非无偿赠与，亦非与其他收益分配互为条件，信托公司对于其转让 的债权真实性应当负责。根据双方约定，其他分配利益与该笔债权转让均为独 立意思表示，并无从属及关联关系，信托公司以程某某在收益分配时有其他获 利为由主张不承担债权差额责任缺乏事实及法律依据，法院不予采信。北京金 融法院判决：

一、撤销一审判决；

二、信托公司于本判决生效之日起七日内向程某某支付26166.43元；

三、驳回程某某的其他诉讼请求。

【法官后语】

资产管理合同或者信托合同中经常约定，在资产管理计划或信托计划终止时，受托管理人以受托财产的现状向委托人或信托受益人进行返还，此类约定一般称为“现状分配”条款。现状分配条款均具有合法性依据。该条款免除了受托管理人按照受托财产的原状向委托人(或信托受益人)进行返还的义务，而实际以委托/信托关系终止时受托财产的现状进行返还。现状分配条款的存在，使得受托管理人不必承担将受托财产进行变现再向委托人(或权利归属人)返还的义务，很大程度上减少了受托管理人处置变现非标资产的风险和

成本。

信托公司应当对其受托管理财产的真实状况负责。案涉债权转让并非一般交易行为中的转让，而是基于信托受托人向受益人进行分配。《中华人民共和国信托法》第二十五条第二款规定，受托人管理信托财产，必须恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。本案厘清了“现状分配”的“现状”认定标准，从债权转让和受托人责任两方面分析了声明债权数额差额赔偿义务的责任来源：基于债权转让，“现状分配”中的债权转让系基于信托财产的管理分配以及受托人责任的履行并非无偿赠与，信托清算和收益分配时转让给投资人的债权并非概括性债权的或有转让，而是明确了具体金额的转让，信托公司应当对其转让债权声明数额的真实性负责；基于受托人责任，债权信托公司作为信托受托人将原有信托财产（债权）分配给受益人，基于其对信托财产（债权）的管理职责及受托人义务，应当对信托财产（债权）的真实状况知情，并应诚实对受托人披露真实情况。

合同约定的追偿及诉讼风险自担的本意指受托人“不承担将未偿还贷款本息全部追回并返还受益人的义务”，债权是否能够全部追回和返还取决于债务人的履行能力；而本案债权差额的形成并非基于债务人履行能力的不足或诉讼风险，而是因为声明债权数额的不真实，某某信托公司以追偿及诉讼风险自担的约定抗辩排除债权差额的追偿，与合同约定的本意不符，缺乏事实及法律依据，法院不予采信。

在进行收益分配时的其他获利不影响受益人向信托公司追偿上述债权差额的分配责任。上述债权转让系基于信托收益分配，并非无偿赠与，亦非与其他收益分配互为条件，其他分配利益与该笔债权转让均为独立意思表示，并无从属及关联关系，其他获利不影响债权差额的追偿。

编写人：北京金融法院 蒙瑞 冯海瑞 王萌萌

资管产品未完成清算情形下投资者损失的认定

—— 甲银行诉甲证券公司营业信托案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

河北省石家庄市中级人民法院(2023)冀01民终9511号民事判决书

2. 案由：营业信托纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):甲银行

被告(上诉人):甲证券公司

【基本案情】

2016年7月,甲银行资产管理中心代表甲银行与甲证券公司、乙银行签订《资管合同》,约定由甲银行委托甲证券公司全权负责管理与运作某策略1号集合资产管理计划,管理期限为3年,其中投资限制为单一信用类固定收益产品发行主体为民营企业的,主体评级需AA+及以上,资产证券化产品债项需AA+及以上;计划管理人应当自资管计划终止之日起10个工作日内,成立由甲证券公司、计划托管人乙银行、相关专业人士组成的清算小组,资管计划清算小组按照监管机构的相关规定进行清算,清算结束后5个工作日内,管理人和托管人应当在扣除清算费用、管理费、托管费和业绩报酬后,将资管计划资产按照委托人拥有份额的比例或者集合资产管理合同的约定,以货币资金的形式全部分派给委托人;若管理人违反本合同导致资管计划资产损失或损害委托人合法权益时,应承担赔偿责任。

合同签订后，甲证券公司以自有资金参与资管计划，持有份额为1000000份，并于同年10月28日将甲银行30000000元资金投向某公司“某01”债券业务。同日，经联合信用评级有限公司评定：某公司主体长期信用等级为AA级，评级展望为“稳定”，拟公开发行的2016年公司债券（第一期）信用等级为AA。该债券主承销商/受托管理人为乙证券公司，发行面值不超过12亿元的“某01”债券，并于2016年10月24日对债券评级及发行主体评级事项在发行公告中进行了提示。

2018年4月18日，甲证券公司向甲银行发送电子邮件《信用债投后管理报告》称：“某01”债券初始主体评级：AA，初始主体评级展望：稳定，最新主体评级：AA-，最新主体评级展望：调低，最新债项评级：AA-，最新评级日期：2018年4月10日。

2017年10月27日、2018年10月29日，甲银行分别收到该资管计划年化收益率为5%投资收益各1500000元，2019年11月28日收到127500元。

后经三方协商对上述《资管合同》管理期限进行展期，最后到期日为2021年10月30日。

2021年11月22日，甲证券公司作出《某策略1号集合资产管理计划终止的公告》，管理人决定于2021年11月22日终止本资管计划，并将于终止之日起10个工作日内成立资管计划清算小组，资管计划清算小组将按照监督机构的相关规定对本资管计划进行清算。

2021年11月11日，广州中院受理乙证券公司诉某公司、邱某甲、邱某乙、陈某某公司债券交易纠纷一案，于2022年6月6日作出某公司向乙证券公司支付债券本金、利息、逾期利息等内容的民事判决。现该判决正在强制执行过程中。

本案诉讼过程中，管理人、托管人及审计机构有关工作人员于2023年5月29日在《某策略1号清算组成员》文件上签名。该文件载明：管理人负责在产品到期后成立清算组进行清算，清算完毕后进行清算财产（如有）分配。目前，该资管计划尚未清算完毕。甲银行请求法院判令甲证券公司向甲银行支付

30000000元的委托资金及相应利息损失。

【案件焦点】

1.甲银行的损失如何确定以及甲证券公司对该损失应否适用与有过错规则承担赔偿责任；2.资管产品未完成清算情形下管理人应否先行赔付投资者损失。

【法院裁判要旨】

河北省石家庄市桥西区人民法院经审理认为：在《资管合同》履行过程中，甲证券公司擅自突破资管合同对主体评级的限制进行投资，未及时、客观、完整披露可能对资管计划的持续运作产生重大影响的事项，拖延履行清算义务，存在明显过错，致甲银行财产权利遭受严重损害，应依法承担赔偿责任；甲银行作为委托人，对资管计划的运作亦应尽到相应的注意义务，其在收到上述《信用债投后管理报告》后，应对案涉债券发行主体及债券的信用评级予以关注，其未及时指出并有效防止损失扩大，亦存在一定的过错，应自担部分损失。根据甲证券公司和甲银行双方的过错程度，法院酌定双方对损失各负90%、10%的责任，即甲证券公司承担损失的90%，甲银行承担损失的10%。关于损失的具体数额，甲证券公司自2021年11月22日作出资管计划终止公告起至今已一年八个多月，其虽然于近期提交了清算小组名单，但清算工作没有取得实质性进展，“某01”债券持有人要求支付债券本金、利息的诉求虽已得到生效判决支持，但尚无执行回款，严重损害了甲银行的利益。甲银行投入该资管计划的30000000元及相应利息，在扣除其已收到的投资收益3127500元后，即为其受到的实际损失。甲证券公司应对甲银行的损失应按上述比例先行赔偿，其赔偿后，如果资管计划经清算取得资金，该资金在甲证券公司已赔偿甲银行实际损失数额范围内归甲证券公司所有，超出该范围的，按《资管合同》约定进行分配，即在依照资管合同扣除清算费用、管理费、托管费和业绩报酬费后，分配给甲银行。

河北省石家庄市桥西区人民法院判决：

一、甲证券公司于本判决生效之日起十日内赔偿甲银行资金损失27000000元及利息(已支付的3127500元从应付利息中扣减);

二、驳回甲银行其他诉讼请求。

甲证券公司不服该判决,提出上诉。河北省石家庄市中级人民法院经审理判决:

驳回上诉,维持原判。

【法官后语】

资管产品未经清算情形下投资者的损失能否认定是目前金融资管案件中常见的争议问题。资管产品到期后,管理人应当按约进行清算,但实践中,受投资项目退出、非现金资产变现、底层资产诉讼程序等各种因素影响,造成资管产品的退出和清算耗时较长,管理人未能及时清算,客观上使投资者利益受损。资管计划项下投资者的损失能否确定原则上应以涉案资管产品清算为前提,但对于诉讼中未经清算的资管产品,若一概以未经清算为由认定损失无法确定,一方面会助长管理人怠于清算的不当行为,另一方面不利于投资者合法权益保护。因此,资管产品未经清算的,应当结合资管产品的具体情况、管理人的过错程度等因素综合认定投资者损失是否客观发生。

“买者自负”的前提是“卖者尽责”。信托法第二十五条规定,受托人应当遵守信托文件的规定,为受益人的最大利益处理信托事务。受托人管理信托财产,必须恪尽职守,履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。该义务被认为是受托人(管理人)的信义义务,包括忠实和勤勉义务,主要体现为谨慎投资义务。从信托法的发展状况来看,谨慎投资义务趋向于主客观相结合的专家谨慎标准,即对这一义务认定程度要高于“处理自身事务同一的注意”。

对于管理人未按照诚实信用、勤勉尽责原则切实履行受托管理职责,造成投资者损失的,应当依法向投资者承担赔偿责任。2018年4月,由中国人民银行、原中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局发布实施的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》即“资管新规”将证券法中的信息披露制度全面引入,要求金融机构应当向投资者主动、

真实、准确、完整、及时披露资产管理产品募集信息、资金投向、杠杆水平、收益分配、托管安排、投资账户信息和主要投资风险等内容。金融机构违反法定义务、合同义务进行信息披露，以及未按照诚实信用、勤勉尽责原则切实履行受托管理职责，造成投资者损失的，应当依法向投资者承担赔偿责任，投资者享有民事赔偿请求权。

依约及时启动清算程序是管理人的一项重要受托管理职责，管理人未依约及时启动清算程序，或启动清算程序后未有效组织清算工作，且违反其他合同义务给投资者造成损失的，应当先行赔偿投资者损失，以切实维护投资者合法权益。同时为合理平衡各方当事人的利益，应明确资管计划清算完成后仍有可分配资金的，管理人可按赔付比例扣除相应款项后再将剩余资金依约向投资者进行分配，即采用管理人先赔付后清算再结算的方式处理。

本案是资管计划管理人未按照诚实信用、勤勉尽责原则切实履行受托管理职责，在资管产品未经清算情形下先行赔偿投资者损失的案例。它对于规范信托行为，保护投资者合法权益，平衡信托当事人利益，推动“资管新规”有效实施，促进信托事业健康发展，具有典型意义。

编写人：河北省石家庄市桥西区人民法院 王跃斌

七、保险纠纷

41

保险代理合同中推荐人签署的保证条款的效力认定

——某保险公司诉姜某某、朱某某保险代理合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京金融法院(2022)京74民终1091号民事判决书

2. 案由：保险代理合同纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 某保险公司

被告(上诉人): 姜某某

被告: 朱某某

【基本案情】

2009年11月1日, 朱某某作为某保险公司的保险代理人, 以姜某某推荐人、直接主管的身份签署《担保书(内)》, 载明“鉴于姜某某同志拟与某保险公司订立保险代理合同, 本人愿自该同志的保险代理合同生效之日起提供以下担保: 该同志在为公司进行保险代理活动中因过错或越权代理给公司和客户造成的经济损失的清偿责任……本人愿就以上事项承担连带清偿责任, 担保期

自公司知道或应当知道上述清偿责任产生之日起四年”。

同日，某保险公司（甲方、委托人）与姜某某（乙方、代理人）签订《保险代理合同书》，约定：“一、双方基于本合同形成委托代理关系，甲方委托乙方代理人身保险业务并支付代理费……七、乙方须遵守国家法律法规、社会公德、诚实信用原则，发生下述行为视为违约：向客户提供虚假资料或误导性的宣传说明、夸大或承诺投资收益及分红红利；阻碍客户履行如实告知义务，明知客户不如实填写单证却不告知甲方；向客户承诺给予保险合同约定以外的保险费回扣或者其他利益……九、甲方应按照基本管理办法及时向乙方支付代理费，犹豫期外，若客户提出退保导致保险合同解除并退还保费，则甲方有权要求乙方退还因该保险合同产生的代理费……二十、乙方越权代理或违反本合同义务，给甲方或客户造成财产损失的，由乙方承担一切责任，如该经济责任确应由甲方先行承担的，甲方有权继续向乙方追偿。乙方违反本合同造成甲方损失的，甲方有权要求乙方担保人承担连带担保责任。”

2013年6月1日至2014年10月13日，姜某某通过夸大投资收益及分红、承诺给予额外利益等方法，诱导吴某某在某保险公司处投保了××保险（分红型）、××终身寿险（分红型）等七份保险。吴某某向某保险公司支付保险费后，该保险公司向姜某某支付首期佣金18836.05元、续佣14004.62元及继续率奖金4974.98元。

2020年9月，吴某某向某保险公司反映姜某某存在误导投保的情况，要求退费。某保险公司与吴某某协议解除保险合同，并退还吴某某保费。

后某保险公司诉至北京市丰台区人民法院，主张姜某某退还首期佣金18836.05元、续佣14004.62元及继续率奖金4974.98元，朱某某对上述债务承担连带责任。

【案件焦点】

《担保书（内）》中推荐人朱某某签署的保证条款是否有效。

【法院裁判要旨】

北京市丰台区人民法院经审理认为：某保险公司与姜某某签订的《保险代理合同书》是双方真实意思表示，内容不违反法律及行政法规的强制性规定，合法有效，双方应当全面履行合同义务。姜某某在向吴某某销售保险的过程中存在诱导行为，直接导致了某保险公司与吴某某解除保险合同并退还保费。姜某某对于某保险公司的损失具有明显过错，应按约定承担违约责任。故对某保险公司要求姜某某退还相关佣金的诉请，本院予以支持。

关于争议焦点，即《担保书(内)》中推荐人朱某某签署的保证条款的效力。本院综合考虑以下因素：首先，从双方缔约能力来看，朱某某与某保险公司系保险代理关系，朱某某具有保险代理从业资质，了解该领域的相关规定，且具有一定的工作经验，故朱某某与某保险公司的缔约能力并不悬殊，其对于是否签署保证条款也具有较高的自主性。其次，从保证条款的内容来看，保险公司应当制定个人保险代理人管理制度，通过明确界定负责团队组织管理人员(以下简称团队主管)的职责，将个人保险代理人销售行为的合规性与团队主管的考核、奖惩挂钩，进而个人保险代理人发生违法违规行为的，保险公司按照有关规定对团队主管追责，故某保险公司通过要求推荐人签署保证条款作为对个人保险代理人的一种风控管理措施，符合行业惯例，具有合理性。最后，从权利义务一致的角度来看，朱某某作为姜某某的推荐人和业务主管，对于姜某某成功代理的保单享有一定的提成收益，也应根据其签署的保证条款履行担保责任。据此，对于某保险公司要求朱某某承担连带清偿责任的诉讼请求，本院亦予支持。

综上，北京市丰台区人民法院判决：

姜某某退还某保险公司首期佣金18836.05元、续佣14004.62元及继续率奖金4974.98元，朱某某对姜某某的上述债务承担连带责任。

姜某某不服一审判决，提起上诉。北京金融法院同意一审法院裁判意见，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

保险代理合同中的推荐保证条款，一般系指推荐人与保险公司约定，被推荐人从事保险代理活动中因过错行为给保险公司造成损失时，由推荐人承担保证责任的条款。相较于传统保证，该类保证条款存在以下特殊性：(1)保证人身份特殊，作为保证人的推荐人通常为保险公司的现任保险代理人；(2)保证范围不确定，包括被推荐人代理保险中的过错行为导致的一切损失，其具体金额存在不确定性，且没有上限；(3)保证期间较长，涵盖被推荐人从事保险代理业务的全部期间，且在主合同终止后不当然结束。

司法实践中，对推荐人签署的保证条款的效力认定并不统一。一种裁判观点认为有效，理由为保证条款是推荐人与保险公司自愿签订，且未违反法律、法规的强制性规定，应属合法有效。另一种裁判观点认为无效：(1)实践中，不少保险公司将该保证条款设置为准入保险代理行业的必要条件，推荐人就条款内容不能与保险公司协商、更改，有格式条款之嫌；(2)由于保证的对象是被推荐人违法违规代理保险造成的损失，保证范围没有上限，保证期间跨度较长，且被推荐人的职业操守、业务能力等难以量化评估，要求推荐人承担保证责任有失公平；(3)推荐人通常也是保险公司的保险代理人，受保险公司管理，类比劳动合同中的保证条款，推荐人处于弱势地位，保险公司要求推荐人承担担保责任以转移风险的约定应属无效。本案采纳保证条款有效的观点。

第一，从法律层面看，推荐人与保险公司系平等主体间的委托代理关系，签署保证条款是推荐人的真实意思表示。依据《保险代理人监管规定》第二条之规定，个人保险代理人是指与保险公司签订委托代理合同，根据保险公司的委托，向保险公司收取佣金，在保险公司授权的范围内从事保险业务的人员。据此，作为推荐人的保险代理人与保险公司是委托代理合同关系，与劳动合同关系不同，保险代理人具有独立的身份，与保险公司不存在隶属关系，不处于明显弱势地位，其在从事保险代理业务时也具有较高的自主能动性。保险公司对保险代理人的规范和管理，但多体现在执业登记、教育培训等方面。据此，保险代理关系与劳动合同关系的管理强度存在显著区别，不应类推适用劳动合

同法中关于用人单位招工时不得要求劳动者提供担保的相关规定认定保证条款无效。

第二，从行业惯例看，推荐人获得管理津贴并承担保证责任，符合利益与风险共存的普适准则。目前，从大多数保险公司对推荐人与被推荐人之间关系的内部规定来看，推荐人并非在签订保证条款后就与被推荐人再无关联，为了通过现任保险代理人推荐的途径扩充增员，各个保险公司均规定被推荐人成为保险代理人后，推荐人可以从被推荐人身上获得“增员奖”“师徒奖”等多种收益，这些收益在行业内部统称为“管理津贴”，且为了激励推荐人更好地通过“传帮带”增进新人的保险知识和推销技能，推荐人的管理津贴也与被推荐人的产出呈持续的正相关关系。此外，随着推荐人从普通成员到团队长等级别的逐渐提高，其对于被推荐人业务的介入程度也随之扩大，当推荐人为主任或类似级别时，其对被推荐人做成的保单具有初审的职责。据此，在行业惯例层面，推荐人与被推荐人存在利益关系，在因被推荐人的保险代理行为获取管理津贴的同时理应承担由此可能产生的赔偿风险。

第三，从社会效果看，保证条款强化推荐人责任，有利于保护广大被保险人的合法权益。个人保险代理人制度引入我国保险市场后，凭借其开展业务的灵活性、便捷性，逐渐成为保险公司开发保险业务的主要途径，但随着该从业群体的规模扩大，诱导购买、隐瞒病史等问题也逐渐暴露。各方利益的不同加之各方掌握信息不对称等因素决定了在保险活动中诚信原则至关重要，任由保险代理人违法违规销售保险将严重侵害保险公司和广大被保险人的合法权益，进而影响到整个保险行业的健康发展。《保险代理人监管规定》第三十六条规定，保险公司应当委托品行良好的个人保险代理人，加强对个人保险代理人招录工作的管理，制定规范统一的招录政策、标准和流程。第五十三条第三款规定，个人保险代理人开展保险代理活动有违法违规行为的，其所属保险公司依法承担法律责任。正如前文所述，保险公司与个人代理人系委托代理关系，诚信销售、规范代理更依赖于保险代理人自律性，于此语境下，为确保招录品行良好、规范从业的保险代理人，加强推荐人对拟推荐保险代理人的指导、督促、

规范，保险公司将保证条款设置为保险代理人的准入条件，约束推荐人谨慎推荐，也具有现实的合理性。

编写人：北京市丰台区人民法院 谭泽泓

北京金融法院 舒翔

42

雇主责任险中雇员的认定不以劳动关系为限

—— 某建筑劳务公司诉某保险公司保险合同纠纷案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

重庆市第五中级人民法院(2023)渝05民终279号民事判决书

2. 案由：保险合同纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):某建筑劳务公司

被告(上诉人):某保险公司

【基本案情】

2017年7月11日，某建筑劳务公司向某保险公司提交建筑施工企业雇主责任保险投保单。同日，某保险公司出具建筑施工企业雇主责任保险保险单，主要载明：投保人与被保险人均为某建筑劳务公司建筑工程项目为某小镇二期项目，每次事故每人人身伤亡责任限额80万元，每次事故每人医疗费用责任限额8万元，累计责任限额1000万元，累计总保险费280800元。建筑施工企业雇主责任保险条款约定，在本保险期间内，被保险人的雇员在本保险合同明细表中列明的区域范围内，从事与被保险人建筑安装工程业务有关的工作时，因

遭受意外事故或者患与业务有关的国家规定的职业性疾病致伤、致残或死亡，依据法律规定应由被保险人承担的医疗费用及经济赔偿责任，保险人依据本保险合同的约定负责赔偿。后某建筑劳务公司支付保险费280800元。

2017年7月，某建筑劳务公司将其承建的某小镇二期项目的建筑劳动施工中的地下室及主体至屋面的所有脚手架工程转包给自然人曾某，由曾某进行搭设和拆除施工，曾某在组织施工中聘用冉某等人从事脚手架的搭设和拆除工作。2018年3月11日，冉某在上述工程项目工作时摔至地面受伤。同日，某建筑劳务公司向某保险公司就发生的事故进行报案。2018年10月28日，重庆市璧山区人力资源和社会保障局作出认定工伤决定书，认定冉某该次受伤属于工伤，并认定由某建筑劳务公司承担工伤主体责任。2018年12月24日，重庆市璧山区劳动能力鉴定委员会鉴定冉某该次工伤为伤残九级。某建筑劳务公司不服仲裁裁决向法院起诉，法院作出民事调解书，由某建筑劳务公司支付冉某一次性伤残补助金等保险待遇损失14万元。后某建筑劳务公司支付完毕前述款项，并向某保险公司提交案涉伤者冉某的住院资料、评残报告等相关索赔书。但某保险公司拒不支付某建筑劳务公司保险费用。某建筑劳务公司遂起诉来院，要求某保险公司支付保险理赔款14万元及资金占用利息。

某保险公司辩称，某建筑劳务公司承接案涉工程后将部分业务违法分包给不具备用工主体资格的曾某，且冉某是曾某聘用，不是某建筑劳务公司的雇员，因此案涉事故不属于保险责任的范围。

【案件焦点】

冉某与某建筑劳务公司不存在劳动关系，冉某在建筑施工过程中遭受的意外事故是否属于雇主责任险的保险理赔范围。

【法院裁判要旨】

重庆市九龙坡区人民法院经审理认为：某建筑劳务公司对某保险公司提交的投保单、保险单、保险条款、免责事项明确说明告知书的真实性均无异议，以上证据系双方真实意思表示，内容未违反法律、行政法规的强制性规定，合

法有效，对双方具有约束力。关于某保险公司认为冉某并非某建筑劳务公司雇员、不应支付保险赔偿金的问题。案涉保险合同对“雇员”并未作出明确界定，在建筑领域转包较为普遍的情形下，对雇员不宜作狭义理解。本案伤者冉某确系在某建筑劳务公司分包的工地务工，系因工受伤，仲裁裁决书及民事调解书也确认了由某建筑劳务公司向冉某承担工伤赔偿责任，某建筑劳务公司已向冉某实际支付了赔偿款。同时，案涉投保单、保险单并未要求某建筑劳务公司提供或明确保险涉及的雇员名单，某保险公司对此亦存在未严格审查或放任的明显过错。综上，某保险公司的前述抗辩理由不能成立，本院不予支持。冉某在某建筑劳务公司投保的工程项目上因工受伤，所受伤害经鉴定为伤残九级。某建筑劳务公司已经按照民事调解书的约定向冉某赔付了14万元，该金额未超过案涉保险合同约定的九级伤残的最高赔付额。某建筑劳务公司主张某保险公司支付保险理赔款14万元的诉讼请求符合合同约定，本院予以支持。

重庆市九龙坡区人民法院判决如下：被告某保险公司在本判决生效之日起十日内赔偿某建筑劳务公司保险金14万元及资金占用利息(以14万元为基数，自2021年10月20日起按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算至保险金实际付清之日止)。

某保险公司不服一审判决，提起上诉。重庆市第五中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项的规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案争议焦点在于，冉某与某建筑劳务公司不存在劳动关系，冉某在建筑施工过程中遭受的意外事故是否属于雇主责任险的保险理赔范围。如何准确把握案涉雇主责任险的保险理赔范围，需结合雇主责任险的功能价值、雇员的边界界定及保险人是否就雇员履行尽责调查义务三要件综合认定。

一、雇主责任险的功能价值

雇主责任险属于建筑领域的主要险种之一，该险种主要系基于雇员向雇主提供一定劳务，雇主为移转分散风险遂向保险人投保，其设立的功能价值主要

从制度规范和保障范围体现。一方面，从制度规范来看。民法典第一千一百九十二条规定了“提供劳务一方因劳务受到损害的，根据双方各自的过错承担相应的责任”。雇主对雇员损害依照其过错程度担责。由此，对雇主而言，其仍具有寻求一种兼具转移风险责任与较为全面赔偿雇员事故损害的险种需求。另一方面，从雇主责任险种的保障范围来看。雇主责任险种的保险标的为雇主对雇员承担的经济赔偿责任，其保障的主体为雇主；雇主责任险种的保险理赔范围包含事故医疗费用、伤残补助金、停工留薪期待遇、住院护理费等各项保险待遇损失，得以有效保障雇员因事故而造成的损失。据此，雇主责任险种的保障范围相较于其他安全生产保险而言，能够更有效兼顾保护雇主与雇员双方的风险利益，实现建筑领域的安全生产保障的最终目的。

二、雇主责任险中雇员的边界界定

对雇员作狭义理解的做法，不符合雇主责任险的功能价值。雇员通常依附于雇佣关系，雇员的边界界定实则依循于雇佣关系的边界界定。实务中，关于雇主与雇员之间的雇佣关系概念界定存在争议，笔者认为雇主责任险中的雇佣关系不宜作狭义理解。一方面，从文义解释角度来看。雇佣关系是指雇员向雇主提供一定劳务，雇主向雇员支付相应报酬所形成的权利义务关系。该种定义之下的标的为提供劳务本身，并未对雇主、雇员之间的基础合同关系来源予以限定，据此可以得出雇佣关系不仅包含基于雇主与雇员之间的劳动关系，也包括雇员提供实际劳务施工而建立的权利义务关系。另一方面，从适应建筑领域转包较为普遍的实践需求来看。首先，基于建设工程施工项目用工的突发性、临时性与集中性，建筑施工单位通常会将涉及劳务施工的部分转包出去，由接收转包主体另行与实际劳务施工主体建立劳动关系或其他权利义务关系。但实务中，鉴于接收转包主体不具备购买雇主责任险的资质或能力，可能导致实际劳务施工主体遭受意外事故后无法获得全面赔偿。其次，实际劳务施工主体基于建筑施工的行为与建筑施工单位具有事实上的利益关联。若以劳动关系的标准径行切断二者之间的事实用工关系，无法将实际劳务施工主体的事故损害归于投保人应依法承担经济赔偿责任范畴，与客观情理不符，也可能使投保人

期待借助雇主责任险分散风险的目的落空。最后，肯定雇主与雇员的雇佣关系不意味着确认双方具有劳动关系。转包的交易常态导致实际劳务施工主体的流动性与分散性，确认实际劳务施工主体与建筑施工单位的劳动关系也与合同相对性不符，雇佣关系的认定仅系尊重实际劳务施工的客观事实，倾斜保护实际劳务施工者的权利。

本案中，某建筑劳务公司作为投保人，其系将案涉建筑劳动施工转包给自然人曾某，曾某在组织施工中聘用冉某从事案涉建筑脚手架的搭设和拆除工作，后冉某遭受意外事故。经有关部门认定冉某系工伤，由某建筑劳务公司承担工伤主体责任，从合同的相对性来看，冉某与某建筑劳务公司之间确实不存在明确的劳动关系，但不阻碍某建筑劳务公司与冉某基于同一工地务工而建立的实质用工关系的判断。据此，可以认定某建筑劳务公司与冉某之间具有雇佣关系，冉某基于雇佣关系具有雇员身份。

三、雇主责任险中保险人对雇员的尽责调查义务

雇主责任险的法律关系中，实质包含两层法律关系：一是保险人与雇主之间的保险合同关系；二是雇主与雇员之间的赔付关系。雇主作为连接保险人与雇员之间的纽带，在雇主未向保险人披露雇员时，保险人具有就雇员及相关情况履行尽职调查的义务。一方面，法律强化保险人的尽职调查义务。由于雇主责任险以雇主与雇员之间的赔偿关系为前提，保险人如何赔偿、是否免责等保险条款具有专业性与复杂性，为避免保险人利用雇主的不知情减轻或免除其保险责任，立法赋予保险人尽职调查义务。在雇主责任险中，保险人有义务要求被保险人提供或明确保险涉及的雇员名单，唯有经保险人尽职调查后才可确保其所承保的保险标的的妥适性。另一方面，保险人未履行尽职调查义务视为具有明显过错。基于保险人作为专业承保机构的职业身份性质，其应当知道雇员的明确对于雇主责任险合同的效力影响，若其仍未要求投保人提供或明确雇员名单并作出合理说明，可以看出保险人主观上不善意，保险人应承担相应的法律后果。雇员在保险人未尽调查义务的事项范围内遭受意外事故，保险人不得违背诚信原则主张雇主与雇员之间的权利义务关系并非劳动关系而拒绝理赔。

本案中，某保险公司在承保案涉雇主责任险种时，并未要求某建筑劳务公司提供或明确保险涉及的雇员名单，其存在未严格审查或放任的明显过错，不得在保险事故发生后据此主张某建筑劳务公司未告知或隐瞒雇员的实际身份，进而免除其保险理赔责任。综上，冉某属于某建筑劳务公司的雇员，其在建筑施工过程中遭受的意外事故属于雇主责任险的保险理赔范围。

编写人：重庆市九龙坡区人民法院 郑曼曼 李静

设置赔付年龄上限条款的效力认定

—— 某物业公司诉某保险公司保险合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

成渝金融法院(2023)渝民终257号民事判决书

2. 案由：保险合同纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 某物业公司

被告(上诉人): 某保险公司

【基本案情】

某物业公司向某保险公司投保雇主责任保险，投保人及被保险人为某物业公司，适用《雇主责任保险条款(2015版)》。2021年，某物业公司对上述到期的保险进行续保，保险期间为1年，仍适该条款。在本次续保的保险单特别约定一栏中载明：“本保单不承担被保险人65岁(含)以上的雇佣人员猝死及突发疾病48小时内死亡赔偿责任。”而《雇主责任保险条款(2015版)》

第三条约定：“在保险期间内，被保险人的雇员因从事保险单载明的业务工作而遭受意外……依法应由被保险人承担的经济赔偿责任，保险人按照本保险合同的约定负责赔偿……（六）在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡。”第五条约定：“下列原因造成的损失、费用和责任，保险人不负责赔偿……但属于本条款第三条第（六）项约定的不在此限。”

2022年，某物业公司员工陈某某在作业时，被发现躺地，于当日经医院抢救无效宣布死亡。重庆市巴南区人力资源和社会保障局认定陈某某受到的伤害属于工伤认定范围，认定为视同工伤，某物业公司承担工伤主体责任。案外人张某某（系陈某某之妻）、陈甲、陈乙（系陈某某之子女）申请仲裁，请求某物业公司支付一次性工亡补助金等费用共计895096元，巴南区仲裁委作出《不予受理通知书》。张某某、陈甲、陈乙遂诉至法院，请求判决某物业公司支付一次性工亡补助金等共计895096元，后法院判决某物业公司支付张某某、陈甲、陈乙一次性工亡补助金等共计992868元，扣除已支付的费用，还应当赔偿892868元，驳回张某某、陈甲、陈乙的其他诉讼请求，某物业公司支付了上述款项。

某物业公司向某保险公司申请理赔遭到拒绝。某物公司向法院提起诉讼，请求判令某保险公司支付保险金992868元。

【案件焦点】

雇主责任保险单中关于“本保单不承担被保险人65岁(含)以上雇佣人员猝死及突发疾病48小时内死亡赔偿责任”系保险范围条款还是免责条款，保险公司是否可以该条免除责任。

【法院裁判要旨】

重庆市巴南区人民法院经审理认为：关于本案争议焦点：第一，该条款从通常理解及文义理解来看，保险人不予赔偿，非承保范围的约定。第二，保单载明适用《雇主责任保险条款(2015版)》，该条款第三条约定在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的应当由保险人赔

偿，而第五条免责条款亦无该项约定。第三，P350号保单系P330号保单的续保单，而在P330号保单中并无“本保单不承担被保险人65岁(含)以上的雇佣人员猝死及突发疾病48小时内死亡赔偿责任”的约定。第四，某物业公司对雇员陈某某投保雇主责任险，某保险公司收取了保险费，未告知不属承保范围的情形。第五，依据《中华人民共和国保险法》第十七条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释(二)》第九条第一款、第十一条的规定，保险人应当对免责条款进行提示，使投保人能够注意到免责条款的存在，提示的方式应当是“足以引起投保人注意的文字、字体、符号或者其他明显标志”。另，保险人还应当对投保人明确说明免责条款，明确说明的内容应当是“保险合同中有有关免除保险人责任条款的概念、内容及其法律后果”，明确说明的形式可以是口头说明也可以是书面说明，明确说明的标准应当是客观的标准，即常人能够理解的程度。保险公司未举证证据证明对上述免责条款向某物业公司予以提示和明确说明，该免责条款亦未采取足以引起某物业公司注意的文字、字体、符号或其他明显标志，故该免责条款不产生效力。根据雇主责任保险(2015版)保险单(保单号为P350)的约定，某物业公司已支付死者陈某某的一次性工亡补助金等费用共计992868元，故对某物业公司诉请，本院予以支持。

重庆市巴南区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第四百六十五条、第五百零九条、第五百七十七条、第五百七十九条，《中华人民共和国保险法》第十七条，以及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释(二)》第九条第一款、第十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条、第一百四十七条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：

被告某保险公司于本判决发生法律效力之日起十五日内支付原告重庆某物业公司保险金992868元。

某保险公司不服一审判决，提出上诉。成渝金融法院经审理认为：对于保险人提供的格式合同文本中的责任免除条款等免除或者减轻保险人责任的条款，

可以认定为保险法第十七条第二款规定的“免除保险人责任的条款”。对于免责条款，保险人应当履行提示和明确说明义务。本案中，某保险公司并未举示证据证明其向某物业公司进行了提示和明确说明义务，且该免责条款亦未采取足以引起某物业公司注意的文字、字体、符号或其他明显标志，故该免责条款不产生效力。某物业公司对雇员陈某某投保雇主责任险，某保险公司收取了保险费，亦未告知不属承保范围的情形。因此，某保险公司应当支付某物业公司保险金992868元。

成渝金融法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

一些离退休人员被物业管理公司或者其他服务企业聘用，但因年龄原因在出现用工事故时，由企业承担用工责任。因此，企业为保障自身经营，转移用工风险，会向保险机构投保雇主责任险。但实践中，企业出现用工事故向保险公司申请理赔时，被保险人(投保人)与保险人因对关键条款属于保险范围还是免责条款产生分歧，最终遭到拒赔，难以达到企业投保目的。如何在审判中准确把握保险范围条款和免责条款的相关认定标准?何种情况下可以认定保险机构对免责条款尽到提示和说明义务?是本案研究探讨的重点问题。

一、保险范围条款和免责条款的区分

保险范围是保险人承担的经济损失补偿或人身保险金给付的责任范围，是保险合同的核心内容，必须加以明确规定，它不仅关系到投保人缴纳保险费的多少，还直接影响到事故发生后，被保险人是否有权就其造成的损害要求保险人给予赔偿及保险人应否承担赔偿责任义务。保险范围的条款并不具有免除或减轻保险人责任的本质特征，故无须加以特别的提示和说明，投保人和保险人在投保合同中签字盖章后即受其约束。

免责条款是指当事人在合同中事先约定的、旨在限制或免除其未来责任的条款。免责条款通常用于保险合同中，指明保险公司不承担或给付保险金的情

况。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释（二）》（以下简称《保险法解释二》）第九条第一款：“保险人提供的格式合同文本中的责任免除条款、免赔额、免赔率、比例赔付或者给付等免除或者减轻保险人责任的条款，可以认定为保险法第十七条第二款规定的‘免除保险人责任的条款’。”对于免责条款是否发生效力，根据《中华人民共和国保险法》第十七条规定，必须以保险人尽到提示和明确的说明义务为前提，若保险人未履行此项义务的，该免责条款不产生效力。本案投保单中载明的“本保单不承担被保险人65岁（含）以上的雇佣人员猝死及突发疾病48小时内死亡赔偿责任”属于免责条款，必须在保险人尽到提示和说明义务后，才产生效力。